

2016년도 제53회 변리사 2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	디자인보호법	120분	모범답안	

[문제-1] (30점)

甲은 디자인 A에 대하여 ‘산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정’에 의한 국제출원서 및 그 국제출원에 필요한 서류를 한국어로 작성하고 우리나라, 미국, 중국(미가입국)을 ‘지정국’으로 지정하여 우리나라 특허청에 2016. 2. 1. 제출하였다. 2016. 2. 8. 특허청장은 디자인보호법 제177조 제2항을 근거로 대체서류의 제출을 명하였고, 甲의 대체서류가 2016. 2. 12. 특허청장에게 도달하였다. 2016. 3. 4. 당해 국제출원이 국제사무국에 접수되었고, 특별한 하자가 발견되지 않아 2016. 3. 25 국제등록부에 등록되었다는 증명서가 甲에게 송부되었다. 한편, 우리나라에서 당해 디자인등록출원이 2016. 7. 20 설정등록되었다. 위와 같은 사실관계를 기초로 아래 설문에 대하여 답하시오.

- (1) 甲의 대체서류에서 보완되어야 하는 사항은 무엇인지 설명하시오. (6점)
- (2) 甲의 디자인 A에 대한 출원에 있어 국제출원의 제출일, 국제등록일, 우리나라에서의 디자인등록출원일이 언제인지 설명하시오. (8점)
- (3) 甲이 디자인 A에 대한 사업 준비기간을 고려하여 일정 기간 디자인 A를 비밀로 유지하고자 할 경우 국제출원서 제출시 유의하여야 할 사항에 대하여 설명하시오. (8점)
- (4) 甲의 디자인 A에 대한 우리나라 디자인권의 존속기간을 설명하시오. (8점)

【출제문제 평가】

본 문제는 2014년 개정법상 도입된 후, 출제되지 않았던 “헤이그 협정에 의한 국제출원”에 대한 주논점 문제였습니다.

보다 구체적으로, 문제에서는 배점으로 나누어 대체사유, 국제출원 서류 제출일과 관련된 국제등록일에 대한 판단, 국제등록공개의 연기 신청 및 존속 기간에 대한 내용을 묻는 문제입니다.

특히, 금번 국제출원 관련 문제는 우리나라 특허청을 수리관청으로 한 간접출원 및 우리나라가 지정국으로 지정된 경우의 특례 제도 등과 관련된 문제가 모두 기출되어 조금은 난이도가 있는 문제로 판단됩니다.

따라서, 개인적인 생각은 본 문제가 첫 문제부터 나와 수험생들이 느끼는 체감 난이도가 높았을 것으로 예상되며, 이에 문제 2 내지 4번부터 풀고, 문제 1번은 마지막에 답안을 작성하는 순서로 기재하시는 것이 좀 더 유리할 듯 해 보입니다.

1. 설문 (1) (6점)

설문 (1)에서는 제177조와 관련된 “기재사항의 확인 등”에서 보완이 필요한 경우 대체서류의 제출 명령 제도에 대해 묻는 문제입니다.

특히, 대체서류에서 보완되어야 하는 사항으로는 반드시 2가지를 지적해주셔야 합니다. 먼저, (1) 우리나라 특허청이 수리관청일 경우 산업통상자원부령으로 정하는 언어는 “영어”이므로, “한국어”로 기재한 서류를 제출할 경우 **제177조 제2항 제1호**에 해당한다는 점 및 (2) 지정국 중 “중국”은 “헤이그 협정”에 의한 국제출원 가능한 국가로 되어 있지 않다는 점¹⁾에서, 지정국의 표시를 허용하는 **제177조 제2항 제6호**에 해당한다는 점입니다.

따라서, 이러한 사항을 명확하게 짚어주시면 될 듯 합니다.

이에 대한 보완은 한국어를 **영어로 기재한 국제출원서 등의 대체서류의 제**

1) 단, 중국은 현재 “헤이그협정”의 가입을 준비 중이며, 향후 2~3년 이내에는 “헤이그협정”에 의한 국제출원이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

출과 지정국 중 “중국”을 삭제한 지정국 기재를 한 국제출원서 등의 대체서류의 제출이 가능하다는 점도 기재하여야 할 것입니다.

II. 설문 (2) (8점)

설문 (2)에서는 국제출원의 제출일, 국제등록일 및 우리나라에서의 디자인 등록출원일이 언제인지 묻는 문제였습니다.

특히, 본 문제에서는 국제출원의 루트, 즉 직접출원과 간접출원의 경우에 대한 설명과 함께, 국제출원서 등의 서류의 효력발생시기와 관련하여 문제 된다는 개요를 기재하여 주신 후, 이와 관련된 법조문으로 제176조의 국제출원서 등의 서류제출 효력발생시기, 제177조 제2항과 제3항에 따라 대체서류 제출 명령이 있는 경우의 국제출원서 도달일을 설명하시는 것이 필요합니다.

특히, 본 문제에서는 수리관청이 국제출원서 등의 서류를 송부받고 1개월 이내에 국제사무국에 송부하여 국제사무국이 접수한 경우에는 수리관청에 국제출원서 등이 도달한 날이, 그리고 수리관청이 국제출원서 등의 서류를 송부받고 1개월 이내에 국제사무국에 송부하여 국제사무국이 접수한 경우에는 국제사무국에 접수된 날이 국제출원의 제출일이자 국제등록일이 될 수 있으며, 이에 따라 우리나라가 지정국일 경우, 이는 우리나라에서의 출원일이 될 수 있다는 설명(제179조 제2항)과 함께, 결국 묻고 있는 국제출원의 제출일, 국제등록일 및 우리나라에서의 디자인등록출원일은 모두 2016년 2월 12일이라는 점을 명시하여 주셔야 합니다.(개인적으로는 답안 중 2016년 2월 1일은 “형식적 국제출원의 제출일”, 그리고 2016년 2월 12일은 “실질적 국제출원의 제출일”이라고 표현하는 방법도 좋을 듯 합니다.)

III. 설문 (3) (8점)

설문 (3)은 국제출원에서의 공개 및 비밀 유지와 관련된 제도 등을 묻고 있습니다.

이와 관련하여서는 먼저 국제출원의 경우 국제사무국이 헤이그협정 제5조 (5)에 따른 국제등록공개를 강제적으로 하고 있다는 점, 국내법상 비밀디자인제도 등은 허용하고 있지 않다는 점(제184조) 및 국제등록공개의 연기 신청이 가능하다는 점(제185조) 등의 내용을 답안에 기재하여 주신 후, 이 경우 제175조 제3항에 따라 도면을 대신하여 견본을 첨부할 수 있다는 내용까지 언급해주시면 될 듯 합니다.

다만, 답안 작성의 비중은 제185조의 내용을 위주로 기재하시되, 국제등록일로부터 30개월까지 연기 신청이 가능하다는 점까지 명확하게 기재해주신다면 좋은 점수를 받으실 수 있을 것입니다.

iv. 설문 (4) (8점)

설문 (4)의 경우, 먼저 제198조의 설정등록의 특례를 기재하여 주신 후(즉, 등록료 납부에 대한 조문의 적용은 없음), 존속기간과 관련된 제199조 제1항 및 제2항 내용을 중심으로 존속기간은 설정등록된 시점인 2016년 7월 20일로부터 발생하여 국제등록일로부터 5년 후인 2021년 2월 12일이라는 점 및 이는 2036년 2월 12일까지 5년마다 갱신이 가능하다는 점을 중심으로 기재하여 주시면 될 것으로 판단됩니다.

[문제-2] (20점)

디자인보호법에 있어서 디자인의 유사는 권리의 성립에서뿐만 아니라 성립된 권리의 효력에 있어서도 매우 중요한 개념이다. 디자인 유사여부 판단의 일반 원칙을 설명하고, 공지부분을 포함하는 디자인의 유사여부 판단방법을 등록요건 판단시와 보호범위 판단시로 나누어 비교 설명하시오.

【출제문제 평가】

본 기출된 문제는 수업시간에도 말씀드린 것처럼, 유사판단에 대한 일반론 기재가 주논점인 문제였으며, 추가적으로 공지부분을 포함하고 있는 경우 등록요건 판단시와 보호범위 판단시로 나누어 설명하는 문제였습니다.

본 문제에 대한 답안은 유사판단에 대한 일반론으로서, 유사 개념의 의의 및 도입 취지를 서두로 심사기준 및 판례와 함께(추가적으로 학설의 내용도 포함되면 좋을 듯 합니다) 물품, 형태 및 참고적 판단방법의 내용으로 기재하시면 되며, 특히 별도의 목차로서 공지부분 포함시 등록요건 판단과 보호범위 판단에 있어서 차이점이 있다는 내용, 즉 대법원 판례 大判2004후2987과 大判2003후762를 중심으로 등록요건 판단시에는 공지된 요소까지 모두 포함하여 관찰하는 것이 원칙이고, 보호범위 판단시에는 공지부분의 중요도는 낮게 평가하여야 한다는 입장에 있다는 내용을 기재하여 주시면 되는 문제였습니다.

[문제-3] (30점)

정보통신기기의 액정표시판에 표시되는 그래픽유저인터페이스(GUI)를 창작한 甲은 자신의 디자인을 화상디자인으로 보호받고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

- (1) 디자인등록출원서에 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 기재함에 있어 甲이 유의하여야 할 사항과 물품의 명칭을 잘못 기재한 경우 그 법적 취급에 대하여 설명하시오. (12점)
- (2) 甲이 출원한 화상디자인이 1디자인으로 인정받을 수 있는지 여부의 판단에 대하여 동적화상디자인인 경우를 포함하여 설명하시오. (10점)
- (3) 甲은 우리나라에서 디자인등록출원을 하기 전에 외국에서 당해 그래픽유저인터페이스를 휴대전화기를 물품명으로 하여 전체디자인으로서 출원하였다. 甲이 이를 기초로 조약 우선권을 주장하면서 우리나라에서 부분디자인으로 출원할 수 있는지 설명하시오. (8점)

【출제문제 평가】

본 문제는 가장 기출될 것으로 예측된 화상디자인에 대한 내용을 묻는 문제였습니다. 이에 대해서는 특히 최근 발행된 “화상디자인 심사지침”의 내용도 다수 포함되어 있어, 이에 대한 준비를 잘하신 수험생들은 비교적 무난하게 생각될 수 있을 것으로 판단됩니다. 단, 내용 중에서도 1디자인 1출원주의에 대한 제40조 제1항 및 제2항과 조약우선권주장출원인 제51조 내용과 관련하여 논점이 출제되어, 각 설문별로 해당 논점에 대한 설명도 반드시 이루어져야 함에 유의하셨어야 할 것입니다.

1. 설문 (1) (12점)

제40조 제2항 규정에 대한 일반론과 함께, 특히 화상디자인의 경우에는 전체디자인 또는 부분디자인으로 출원 가능하며, 잘못 기재한 경우로서, 총괄

명칭, 화상디자인이 표시되는 물품의 특징이 이루어지지 않은 경우, 기능 표현방법 표현대상 등을 기재한 경우, 구조 형상 등을 기재한 경우 및 물품의 명칭과 도면과의 차이가 있는 것 등을 구체적으로 언급하시면서 관련 예를 추가로 기재하시면 좋은 점수를 받으실 수 있을 것입니다. 또한 물품의 명칭을 잘못 기재한 경우 제40조 제2항 위반으로 취급되며, 또한 이에 대한 관련 심사 및 등록 후의 취급과 추가적으로 물품의 명칭이 전혀 기재되지 않은 경우 화상디자인 자체로 취급받아 제33조 제1항 본문의 공업상 이용 가능성 위반의 가능성도 있음을 언급하신다면 플러스 점수를 받으실 수 있을 것입니다.

II. 설문 (2) (10점)

제40조 제1항 규정과 함께, 특히 화상디자인의 경우, 전체디자인 또는 부분디자인으로 가능하고, 부분디자인의 경우 물리적으로 분리된 2이상의 부분이 포함된 경우 같은 표시부를 제외하고는 2디자인으로 인정될 수 있다는 점과 형태상 또는 기능상 일체성 인정과 관련된 예외를 설명해주시면 될 듯합니다.

추가적으로, 동적화상디자인의 경우 형태적 관련성 및 변화의 일정성을 모두 만족하여 1디자인으로 성립될 수 있다는 점과 함께, 별도 화면, 화상 내 도형의 단순한 변화 등의 1디자인으로 성립되는 예와 아닌 예를 각각 구체적인 예와 함께 언급하여 주시면 보다 좋은 배점을 받으실 수 있을 것으로 판단됩니다.

iii. 설문 (3) (8점)

먼저 제51조에서 규정된 조약우선권주장출원 제도에 대한 의의, 취지 및 요건을 쓰되, 요건 중 주체적 요건, 객체적 요건 및 시기적 요건을

작성하여야 하며, 특히 객체적 요건과 관련하여 디자인의 동일성 판단을 별도 목차를 잡아 기재해주셔야 합니다. 이 경우, 원칙적으로 제1국 출원이 전체디자인인 경우 우선권주장출원은 전체디자인이어야 디자인의 동일성이 인정되되, 특히 제1국에서의 제도 등을 고려 전체디자인만이 인정되는 경우(예를 들어 중국 등)라면, 실질적 디자인의 동일성 판단에 있어, 물품의 명칭, 디자인의 설명 및 물품류 구분 등을 종합적으로 고려했을 때 실질적 동일성이 인정되더라도 인정될 수 있다는 점을 명시적으로 기재해주셔야 합니다.

[문제-4] (20점)

디자인보호법은 디자인의 성립요건을 충족하고, 공업상 이용가능성, 신규성 및 창작비용이성을 디자인등록의 적극적 요건을 구비한 디자인이라 하더라도 디자인등록을 받을 수 없는 디자인을 규정하고 있다. 디자인등록을 받을 수 없는 디자인 중 ‘타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인’(디자인보호법 제34조 제3호)에 대하여 설명하시오.

【출제문제 평가】

본 문제는 제가 수업 시간에도 강조드린 것처럼, 올해 출제가 예상된 부등록사유 중 하나인 제34조 제3호에 대한 단문 문제입니다. 특히, 본 문제에서는 제34조 제3호와 관련되어 일반적인 단문을 그대로 작성하시되, 구체적으로 기재하는 것이 바람직합니다.

부등록사유에 대한 공통된 내용을 먼저 언급하셔도 무방하되, 특히 문제에서 직접적으로 묻고 있는 제34조 제3호를 구체적으로 예를 들어서 명확하게 기재하여 주시는 것이 중요합니다. 추가적으로 문제에서 언급된 서두 내용으로 볼 때, 제34조 규정은 “33조에도 불구하고”라는 법조문 용어를 현출해주시는 것도 중요할 것으로 판단됩니다.

2016년 디자인보호법 2차 시험 기출 문제에 대한 총평

무더운 날씨가 한 걸음 먼저 다가온 2016년, 올 한해도 정말 수고하셨습니다.

문제 중에는 특히, 문제 1번이 출제는 예상되었던 논점이었으나, “헤이그 협정” 관련 단문형 문제가 아닌 사례형 문제로 나와 수험생들이 느끼는 체감 난이도는 좀 높았을 것으로 예상됩니다.

따라서, 문제 1번을 읽고 문제 2번 내지 4번을 먼저 기재하신 후, 문제 1번을 차후에 기재하시는 방안도 고려해볼 만한 좋은 임기응변(?) 자세였을 것으로 판단됩니다.

그러나, 문제 1번의 경우에도 배점이 각각 나누어져 있으며, 이에 대한 구체적인 날짜 언급에 대한 답이 있는 부분도 있기 때문에 관련 법조문 내용과 함께 적으셨다면 충분히 높은 점수 획득도 가능한 문제였다고 보입니다.

이런 부분들을 종합적으로 고려할 경우, 금년 디자인보호법 선택자들이 전년도 대비 증가하였음을 고려하여, 합격자의 수는 작년과 비슷한 수준을 보일 것으로 예상됩니다.

여러분에게 다시 한번 말씀드리고 싶은 말은, 생각하시는 것보다 디자인보호법 점수는 높게 나올 것이라는 점 꼭 드리고 싶습니다. 합격에 대한 자신감을 가지시기 바랍니다.

그동안 정말 수고하셨다는 말씀을 다시 올리면서, 그럼 11월에 있을 합격자 환영회에서 뵙겠습니다.

감사합니다.

2016년 7월 25일

서상덕 배상